Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 32ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº **0163913-58.2022.8.17.2001**

AUTOR: JADEILDA IVANISE DE LUCENA CARVALHO, FLAVIA CATARINA FARIAS MELO

RÉU: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

SENTENÇA

Trata-se **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE HOME CARE E DANOS MORAIS ajuizada por JADEILDA IVANISE DE LUCENA CARVALHO**, em face de **FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA**, a autora firmou com a Ré contrato de Adesão, em razão do qual lhe foi atribuído o código de identificação cartão nacional 705607498568217 - ASSEFAZ RUBI.

Afirma ser portadora de DIABETES MELLITUS; D. ALZHEIMER MODERADA/GRAVE, SÍNDROME DA FRAGILIDADE E INFECÇÕES URINÁRIAS DE REPETIÇÃO, o que a torna dependente de terceiros para realizar todas as atividades da vida diária.

Aduz, que, em razão do seu grave quadro clínico, atualmente se encontra internada, contudo, tendo os médicos especialistas que a assistem indicado, como condição para a alta hospitalar, o gerenciamento domiciliar, HOME CARE nos seguintes termos:

"*Fisioterapia motora e respiratória 3 vezes por semana; Fonoaudiologia 2 vezes por semana; Visita de nutricionista mensal; Visita de enfermagem mensal; Visita médica mensal; Cama Hospitalar; Colchão Pneumático; Cadeira de Rodas de banho; Cadeira de Rodas de transporte; Curativos Especiais para evitar lesões por pressão; Medicamentos de uso contínuo; Medicações parenterais intermitentes (por exemplo uso de antibióticos para tratar infecções futuras em domicílio e evitar internamentos hospitalares); Ambulância para intercorrências e Alta hospitalares.*"

Não obstante a prescrição médica, a requerida teria acolhido parcialmente o que lhe foi indicado, concedendo apenas as seguintes terapias: "*Fisioterapia motora e respiratória 3x/semana; Fonoterapia 2x/semana; Visita médica mensal; Visita de*

nutricionista mensal".

Assevera que a negativa parcial tem forçado a sua permanência no ambiente hospitalar.

Reputa como ilícita a atitude da demandada e postula a concessão de tutela antecipada *initio litis e inaudita altera pars*, a fim de ser determinado à requerida que a REINCLUA NO PROGRAMA PAIC/ ZELAR ATENDIMENTO DOMICILIAR, consoante prescrição médica, por período suficiente para cobrir o tratamento, sem prejuízo de outros tratamentos prescritos. Pede, ainda, que ao final a tutela provisória seja confirmada, e que seja imposto à demandada a obrigação de pagar indenização a título de compensação pelos danos morais decorrentes da negativa de autorização em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A inicial foi instruída com documentos.

Custas recolhidas.

Liminar indeferida.

Citada, a ré apresentou contestação de ID 124644951, na qual defende a inaplicabilidade do CDC, em virtude do disposto na Súmula 608, do STJ, sustentando, no mérito, que o tratamento domiciliar com enfermagem foi prescrito com o fito de transferir ao plano o dever de prestar amparo à autora, de exclusiva responsabilidade dos familiares.

Defende a tese de que não lhe pode ser atribuída a obrigação de cobrir procedimento expressamente excluído do contrato e que não consta do rol de eventos de cobertura obrigatória elaborado pela ANS.

A defesa foi instruída com documentos.

A autora, intimada, replicou sem especificar provas. A ré, pugnou pela produção de prova pericial, com o fito de determinar a desnecessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente.

Volveram os autos conclusos.

É o que tinha a relatar.

DECIDO.

1. Do julgamento antecipado da lide.

O feito comporta julgamento antecipado, na forma do Art.355, I, do Diploma de Ritos. É que, compulsando os elementos produzidos pelas partes, se infere desnecessária a dilação probatória, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental apresentada. Eventual produção de prova oral ou pericial não terá o condão de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde.

Encontra-se pacificado na doutrina e na jurisprudência que o julgador, visualizando nos autos elementos suficientes para a apreciação das questões postas pelas partes, pode dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo, e julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa (Theotônio Negrão. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 31ª Edição. São Paulo: Saraiva, p. 397).

Nessa diretiva, Cândido Rangel Dinamarco é preciso ao pontuar: "a razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento" (Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III. São Paulo: Malheiros, p.555).

Na mesma linha de raciocínio, o STF firmou entendimento de que "a necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (STF - RE 101171, Relator Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984, p.20990). Para a Corte, "o propósito de produção de provas não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado (STF -RE 96725/RS, Rel. Min. Rafael Mayer).

A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo caminho:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DEDEFESA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. 1. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Desse modo, não há incompatibilidade entre o art. 400 do CPC, que estabelece ser, via de regra, admissível a prova testemunhal, e o art. 131 do CPC, que garante ao juiz o poder de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010).

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA POSTULADA. REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Sendo o magistrado destinatário final das provas produzidas, cumpre-lhe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, indeferindo as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art.130, parte

final).2- A mera alegação de haver o juízo sentenciante julgado antecipadamente a lide, com prejuízo da produção das provas anteriormente requeridas, não implica, por si só, em cerceamento de defesa. 3- Indagação acerca da imprescindibilidade da prova postulada que suscita reexame de elementos fático-probatórios da causa (Súmula n°7). Precedentes do STJ. 4- Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no Ag 1351403/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe29/06/2011).

Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. (STJ. REsp n°2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, QUARTA TURMA). No mesmo sentido: RSTJ 102/500 e RT 782/302.

2. Do Mérito.

2.1. Sobre a Aplicação do CDC.

A matéria trazida aos autos deve ser dirimida a luz dos parâmetros estabelecidos na Súmula nº 608, do C. STJ, segundo a qual, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.04.2018, DJe17.04.2018; na mesma oportunidade, cancelou-se a Súmula nº 469), sem, contudo, afastar a ponderação da função social que, nos termos do artigo 421, do Código Civil, limita e modela a liberdade de contratar.

Como ensina Nery, em suas *Soluções Práticas*, a “função social dos contratos é uma peculiaridade normativa do Código Civil Brasileiro. Tal como a língua, existem determinadas circunstâncias determinantes de uma feição própria do sistema jurídico de cada nação a ponto de falar mesmo de uma ‘circunstancialidade’ de cada país. Assim é que existe um direito brasileiro. Neste direito encontra-se a cláusula da função social dos contratos” (vol. II, n. 2, pp.80-81), como decorrência lógica do princípio constitucional dos valores da solidariedade e da construção de uma sociedade mais justa, previsto no inciso I, do artigo 3º da Constituição Federal, que impõe a boa-fé como requisito para a valoração dos contatos (Reale-Reali Jr. Questões, n. 10, p. 125).

Em outros termos, na Ordem Jurídica Brasileira, em maiúsculo, não se pode conceber o contrato apenas sob o ponto de vista econômico, dada a magnitude constitucional da norma que impõe à sua concretização a observância irrestrita à sua função social.

2.2. Sobre a Saúde Suplementar.

A Constituição da República, em seu art. 196, prescreve que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem (...) ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O Constituinte, porém, foi mais além e não limitou a prestação de serviços de saúde ao Estado, facultando aos particulares atuarem de forma complementar e suplementar à atividade estatal. Solange Oliveira, ao tratar do assunto, destaca:

“A forma de assistência complementar que está destinada à iniciativa privada no sistema público de saúde ocorre quando o prestador de serviços de saúde atua por meio das diretrizes do SUS, mediante contrato de direito público ou convênio, dando-se preferência às entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. Assim, a assistência complementar é parte da obrigação do SUS. (...). Por outro lado, a assistência suplementar atua sem qualquer vínculo (ela é extraordinária) direto com o SUS, por meio de consultórios, laboratórios, clínicas e hospitais particulares, ou de planos e seguros privados de saúde. Portanto, a atuação da iniciativa privada no âmbito da saúde se dá deforma suplementar à rede pública quando seu acesso é garantido apenas àqueles que tiverem condições financeiras de contratar seus serviços, sendo as contraprestações sanitárias delimitadas por meio de um contrato privado, bilateral e de adesão, estabelecido entre o agente econômico e o particular interessado na contratação de seus serviços. ” (O direito à saúde na Constituição brasileira: complexidades de uma relação público-privada no SUS. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017).

Depreende-se do exposto acima que os planos de saúde não estão compreendidos no conceito de saúde complementar, mas como suplementar, e isso significa que as operadoras não estão vinculadas às diretrizes do Sistema Único de Saúde (universalidade e integralidade), mas fornecem atendimento segundo os riscos assumidos em contrato.

Entretanto, por se tratar de serviço de relevância pública, cabe ao Poder Público "dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle" (Art. 197, da Constituição).

A regulamentação se deu, num primeiro momento, com a edição da Lei 9.656/98, que criou o Plano-Referência, isto é, um conjunto mínimo de coberturas que todas as empresas que operassem planos de saúde deveriam fornecer.

O contrato de plano privado de assistência à saúde foi definido no art. 1º, inc. I, da Lei n. 9.656, de 1998, que o caracteriza como a:

“(...) prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais apreço pré ou pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.”

A finalidade dele, portanto, é garantir ao beneficiário, o qual contribui periodicamente para a formação e manutenção de um fundo pecuniário do plano, o direito ao atendimento médico, nos casos de sinistralidade contratualmente coberta, assegurando, ainda, que o custo financeiro pelo procedimento prestado corra às expensas da operadora responsável por sua administração.

A legislação de regência, cuidou ainda de ressalvar procedimentos e coberturas cuja prestação não seria obrigatória, em típico dirigismo contratual. Vejamos o que dispõe o art. 10 da Lei dos Panos de Saúde:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - Tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV -tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI- fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001); IX- tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. (...) §4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS.

A Lei 9.961/2000, que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, estabeleceu, em seu art. 4º, inciso III, que compete à autarquia "elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades".

Em síntese, o Estado permitiu aos particulares explorar serviços de saúde e estabeleceu o conteúdo mínimo - doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde -, ressalvou a possibilidade de não fornecimento de alguns serviços - incisos do art. 10, da Lei 9.656/1998 - e conferiu à agência reguladora a competência para dispor sobre o rol de procedimentos que constituirão o plano-referência, rol este periodicamente atualizável.

Através deste mecanismo, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ente regulador do setor, estabelece quais são os procedimentos médicos e eventos de saúde serão obrigatoriamente cobertos pelas operadoras de saúde suplementar, o que confere

maior previsibilidade dos custos e além de segurança jurídica aos beneficiários do plano de saúde, que poderão saber de antemão quais os procedimentos cobertos pelo contrato firmado com a operadora.

A adoção do mecanismo regulador eleito pelo legislador federal permite, assim, uma um adequado equilíbrio financeiro dos contratos de prestação de assistência médica e hospitalar, ao mesmo tempo que faculta a oferta de planos de saúde que tenham custo variável de acordo com as coberturas oferecidas.

A respeito, colaciono entendimento doutrinário do professor Marcos Ehrhardt Júnior:

"Em um contrato de plano de saúde o consumidor almeja o atendimento dos procedimentos e tratamentos médico-hospitalares abrangidos pela cobertura que contratou, ao passo que o fornecedor objetiva o recebimento as mensalidades pactuadas. Contudo, o raciocínio não é tão simples quanto parece. Tais contratos são formalizados por uma lógica econômica que o distingue dos demais contratos de mesma classificação. (...) Primeiro, denote-se que têm como objeto a prestação de serviços de saúde, constituindo, por conseguinte, instrumento indispensável para a preservação da dignidade da pessoa humana. Observa-se também que a prestação e a contraprestação contratual não são equivalentes, mas, sim, proporcionais. Assim como ocorre nos contratos de seguro, um dos pilares do contrato de plano de saúde é o cálculo atuarial, que determina a mensalidade a ser paga pelo usuário, de acordo com a cobertura que lhe é ofertada. (...). Elaborado com base no rol de procedimentos obrigatórios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar de acordo com a atual Resolução Normativa nº 338 e em conformidade com as isenções previstas no art. 10 da Lei Federal nº 9.656/98, o aludido planejamento reflete nas próprias cláusulas contratuais. As garantias constantes no instrumento de contrato devem ser fixadas de acordo com o cálculo atuarial e com a relação de mútuo estabelecida para cada contratante. Inclusive a própria ANS detém competência para exercer controle sobre as reservas financeiras das Operadoras, obrigando-as a criar um Fundo Garantidor do Segmento de Saúde Suplementar; e a Lei Federal nº 9.656/98, em seu art. 22, § 1º,estabelece a obrigatoriedade da elaboração do cálculo atuarial conforme as normas expedidas pelo Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), e prevê, ainda, em seu art. 35-F que a assistência à saúde deverá observar os termos da lei e do contrato firmado entre as partes". (EHRHARDT JÚNIOR, Marcos Augusto de Albuquerque; et al. Limites da Intervenção Judicial nos Contratos de Plano de Saúde. In: Revista Brasileira de Direito Comercial. 8. Ed. - Dez/Jan 2016).

Vale relembrar que as operadoras de planos de saúde atuam no ramo da saúde suplementar, e não complementar, não estando sujeitas às diretrizes do SUS, especificamente ao atendimento integral, o que - segundo o entendimento deste magistrado - permite concluir que o Legislador Constituinte implicitamente conferiu a tais empresas a faculdade de limitar a abrangência da cobertura securitária, com as ressalvas já feitas acima.

2.3. Sobre a taxatividade do rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS).

A teor do Enunciado 21 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: "Nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei nº 9.656/1998, recomenda-se considerar o rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas".

Seguindo esta orientação, **a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu, por maioria, ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrir em tratamentos não previstos na lista**, em Acórdão assim ementado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO. (STJ – SEGUNDA SESSÃO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.886.929 – SP. Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Documento: 160376796 - Site certificado - DJe: 03/08/2022).

Contudo, o Colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor, definindo a seguinte tese:

"11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1. **O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo**; 2. A **operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento**

eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. **Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que**: (i) **não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar**; (ii) **haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências**; (iii) **haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros**; e (iv) seja realizado, **quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS"** (STJ – SEGUNDA SESSÃO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.886.929 – SP. Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Documento: 160376796 - Site certificado - DJe: 03/08/2022).

2.4. Sobre a validade da exclusão contratual do atendimento em ambiente domiciliar.

No caso em análise, **a questão de fundo diz respeito, primeiramente, à validade da restrição contratual ao fornecimento do serviço**.

A despeito da prescrição médica justificando a adequação e necessidade do HOME CARE, a demandada negou a cobertura ao fundamento de que no instrumento contratual firmado entre as partes não houve a inserção entre os serviços a serem prestados obrigatoriamente pela demandada, a realização do atendimento em ambiente domiciliar e o fornecimento de maquinário hospitalar.

O Regulamento do Plano, acostado no evento de ID 14644958, estabelece no inciso I, do art. 22 que "**atendimentos realizados em ambiente domiciliar (home care), estão excluídos das coberturas concedidas pela ASSEFAZ**".

Acerca da temática **a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de considerar** "abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp 2.007.152/CE, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Verbis:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. DEVER DE COBERTURA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, especialmente no caso dos autos, em que o Tribunal de origem verificou a existência de excepcional necessidade de cobertura do tratamento, o que somente poderia ser revisto mediante o reexame do acervo fático-probatório dos autos, obstado, em recurso especial, pelo enunciado da Súmula n.º 7 do STJ. 3. O Tribunal de origem concluiu que a parte ora recorrida comprovou a existência de circunstâncias fáticas capazes de ensejar dano moral, o que somente poderia ser revisto mediante o reexame das provas dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n.º 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido" (STJ –Terceira Turma - AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2007152 - CE (2022/0172150-2). RELATOR MINISTRO MOURA RIBEIRO, j. 22/11/2022).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.107.542/RJ, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022; AgInt no REsp 2.019.084/SP, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022; AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021.

Patente, portanto, a abusividade da restrição.

2.5. Sobre a excepcional possibilidade de impor à Seguradora a obrigação de disponibilizar o tratamento domiciliar, ainda que não figure como procedimento obrigatório no Rol da ANS.

A **outra questão que se põe**, refere-se, especificamente, se a situação talhada nos autos, qual seja, a negativa de tratamento domiciliar com base em norma contratual abusiva, autoriza a intervenção judicial impositiva da sua disponibilização, ainda que não conste como de cobertura obrigatória no Rol da ANS?

Entendo que sim. Explico:

É certo que em consonância com o recente Regulamento 465/2021, elaborado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no artigo 35 da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, **o serviço de internação domiciliar não é de cobertura obrigatória**. Ao dispor sobre ele, o Regulamento estabelece:

"Art. 13. **Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual**, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.º 9.656, de 1998.

Parágrafo único. **Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes**".

Segundo o Parecer Técnico nº 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, "o termo home care refere-se aos serviços de atenção domiciliar, nas modalidades de assistência e internação domiciliar, regulamentados pela Resolução RDC nº 11, de 26 de janeiro de 2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA", as quais, por sua vez, são definidas, respectivamente, como "conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio" e "conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada".

Consta, ainda, do citado parecer:

"Cumpre assinalar que a Lei n.º 9.656/1998 não inclui a Atenção Domiciliar entre as coberturas obrigatórias. Para uso domiciliar, a lei garante o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sondavesical de demora e coletor de urina com conector (art. 10-B).

Além disso, a Lei deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais, adjuvantes e para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos (art. 12, inciso I, alínea c, e inciso II, alínea g). No mesmo sentido, a RN n.º 465/2021 também não prevê cobertura obrigatória para procedimentos executados em domicílio. Todavia, nos termos do art. 2º da resolução normativa em questão, as operadoras de planos de saúde poderão oferecer, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual, cobertura maior do que a obrigatória delineada pelo Rol da ANS.

Destaca-se que, **na saúde suplementar, os Serviços de Atenção Domiciliar - SAD, na modalidade de internação domiciliar podem ser oferecidos pelas operadoras como alternativa à internação hospitalar. Somente o médico assistente do beneficiário poderá determinar se há ou não indicação de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar e a operadora não pode suspender uma internação hospitalar pelo simples pedido de internação domiciliar**.

Ao fixar os parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos no rol, a Segunda Sessão ao STJ, nos Embargos de Divergência (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.886.929 – SP. Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão) apontados como paradigma, estabeleceu que:

(1) A operadora de plano ou seguro de saúde **não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol**.

No caso particular em exame, verifica-se que a autora é idosa, contava com **87 anos**, quando da propositura da demanda, apresentava grave quadro clínico, em razão do qual foi solicitado o tratamento **DOMICILIAR** a fim de lhe proporcionar **melhor qualidade de vida, e porque**, tal serviço se presta para uma maior eficácia do tratamento das doenças (**DIABETES MELLITUS, D. ALZHEIMER ODERADA/GRAVE, SÍNDROME DA FRAGILIDADE E INFECÇÕES URINÁRIAS DE REPETIÇÃO)**, que lhe acometem, fragilizam e a posicionam como dependente de tratamento domiciliar especializado.

O outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que isentaria a Seguradora de disponibilizar o Home Care seria o Internamento Hospital, recusado pelo médico assistente porque, além de expor à saúde da Segurada a maiores riscos, se revelava potencialmente danoso à sua qualidade de vida e à eficácia do tratamento.

Não foi apontado pela Seguradora outro substituto terapêutico constante do rol da ANS, para suprir a necessidade da segurada, nem tampouco o tratamento domiciliar constitui expressamente rechaçado pela ANS.

O Home Care tem comprovada eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, e figura como procedimento expressamente recomendado pelo NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS-TJDF, conforme se infere da Nota Técnica – Saúde Complementar, emitida 26/08/2022, no âmbito do Processo nº 0760980-17.2021.8.07.0016, que tramitou na Primeiro Turma Recursal do TJDF. Ao tratar do assunto, os técnicos pontuaram:

"Home Care é o termo em inglês para a assistência médica domiciliar. Essa modalidade, hoje uma obrigação do SUS e da saúde suplementar, visa permitir desospitalização precoce dos pacientes e tem como principais usuários pacientes com doenças crônicas e grande dependência para cuidados da vida diária e de enfermagem. Dentro de um modelo de Home Care existem inúmeras formas de atendimento, tais como fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista ou aplicação de medicação via endovenosa (ou intramuscular); monitoramento e atendimentos médico e enfermagem. Além disso, há ainda a "verdadeira" internação domiciliar, que consiste na presença de um técnico de enfermagem na residência por 12 ou 24 horas por dia com um maior aparato médico hospitalar de maior complexidade (ex: ventilador mecânico), além de dispositivos médicos como traqueostomia, gastrostomia. Segundo a Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes: Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão

nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. A elegibilidade de um paciente para Home Care pode ser definida pela operadora ou por normas da regulação de saúde. Não há uma lei específica sobre o assunto. Contudo, os critérios da ABEMID (Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar) e da NEAD são as mais utilizadas. Segundo a entidade nacional representativa das empresas que atuam em Atenção Domiciliar à Saúde (NEAD), assim se conceitua assistência domiciliar e internação domiciliar: - Assistência Domiciliar: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio – Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 11, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - Internação Domiciliar: nome dado ao serviço prestado no domicílio do paciente, em substituição ou alternativo à hospitalização, por equipe técnica habilitada e multiprofissional, com estrutura logística de apoio e integrado a um programa específico com essa finalidade. O serviço é realizado por instituição médica de assistência domiciliar registrada no Conselho Regional de Medicina e, obrigatoriamente, deve ser coordenado e supervisionado por médico (NEAD até 2006). Segundo RDC nº 11, ANVISA, trata-se do conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. (...) A classificação dos pacientes, em alta complexidade, apontada na tabela ABEMID, como acima de 19 pontos e 24 horas de assistência de enfermagem, pelo alto grau de dependência de cuidados, refere-se a pacientes que necessitam dos mesmos aparatos utilizados durante sua internação hospitalar em unidades de cuidados intensivos e semiintensivos. Assim, ao serem transferidos ao domicílio, precisam durante sua internação domiciliária do mesmo quantitativo de 24 horas de assistência de enfermagem e de uma equipe multiprofissional. Os cuidados em domicílio são classificados, como cuidados de enfermagem, cuidados básicos e cuidados de ajuda em domicílio, sendo tais cuidados classificados em ações sociais, ações familiares e outras prestações de cuidados. Os cuidados básicos são realizados por profissionais com conhecimentos obtidos de formação básica, semelhantes ao técnico de enfermagem do Brasil. Os cuidados de ajuda em domicílio são oferecidos, em especial, aos idosos e incluem a estrutura de manutenção das atividades de vida diária todos os dias da semana e, atualmente, está sendo estendido a 24 horas por dia".

Inequívoco, portanto que, no caso concreto, o tratamento domiciliar se afigurava como melhor alternativa à manutenção do internamento hospitalar da autora, o que, por si só desautorizava à Segurado lançar mão da faculdade prevista no artigo 2º da RN n.º 465/2021. Entretanto, em razão da excepcionalidade, é legítimo assegurar-lhe o direito de limitar o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RECURSO ESPECIAL Nº 2.017.759 - MS (2022/0241660-3), relatado pela Eminente Ministra Nancy Andrighi, cujo Acórdão foi assim ementado

“HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes.6. **Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente – idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado – na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital**. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ. TERCEIRA TURAM. RECURSO ESPECIAL Nº 2.017.759 - MS (2022/0241660-3), Relatora Ministra Nancy Andrighi, Julgado em 14/02/2023. Documento: 2256042 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 16/02/2023).

3. Sobre os danos morais alegados pela demandante.

Assiste razão à autora quando pugna por verba indenitária compensatória em razão dos danos morais resultantes de conduta da demandada.

O descumprimento contratual, em regra, não gera dano moral. Entretanto, o agravamento da aflição psicológica do usuário de plano de saúde, que, para além da sua específica condição debilitada se vê abandonado e desguarnecido da proteção contratualmente acertada, inegavelmente configura hipótese de ofensa ao seu patrimônio imaterial.

A despeito da não incidência no caso em tela das normas previstas do Código de Defesa do Consumidor. O exercício da livre iniciativa para contratar é limitado valores sociais (arts. 1º, IV; 170, *caput* e V; e 173, § 4º, da Constituição da República), é dever irrenunciável da demandada ser transparente e agir de boa-fé (objetiva), assegurando o equilíbrio contratual com o atendimento das necessidades dos seus segurados.

A proteção à saúde é um dos sustentáculos da dignidade da pessoa humana constitucionalmente assegurada e dirige-se à realização dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, entre eles, a liberdade, a justiça e a solidariedade.

Nesse contexto, quando a seguradora ré se nega a fornecer ou a autorizar, procedimentos, medicamentos, exames diagnósticos e materiais demandados pela equipe médica no período em que o segurado se encontra fragilizado física e psiquicamente em razão do adoecimento afigura-se como prática abusiva, fundada no manejo distorcido do poder econômico, em detrimento da defesa e do respeito ao segurado.

A indevida negativa de autorização de procedimento, sem causa fática ou legal que a legitime, constitui abuso de direito que se amolda ao enunciado do artigo 186 do Código Civil e por isso é ato ilícito, ensejador de reparação através dos critérios compensatórios e sancionatórios, visando à recomposição do patrimônio moral violado, com base nos efeitos do ato lesivo, de modo a proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido.

A jurisprudência, com a qual me filio, em situações análogas não tem trilhado caminho diverso:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 608 DO STJ. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONTRATUAIS CIVIS. **NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS THACOSIL E COLA BIOLÓGICA NECESSÁRIOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO**. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Tratando-se de entidade caracterizada pela autogestão e sem fins lucrativos, limitada a funcionários do Banco do Brasil S/A e seus parentes, ou seja, sem atuação no mercado de consumo, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 608.2. Todavia, ainda que afastada a aplicação do Código Consumerista, é fato que os princípios contratuais previstos na legislação civilista devem ser observados, notadamente a função social dos contratos (art. 421) e os princípios da probidade e boa-fé objetiva (art. 422), além da interpretação mais favorável ao aderente, em casos de contratos de adesão (art. 423).3. Analisando as razões trazidas aos autos, entende este Colegiado que a tese defendida pelo plano de saúde apelante não é suficiente para justificar a não viabilização imediata do procedimento terapêutico requisitado, pois, considerando que a disponibilização de tratamentos médico-hospitalares necessários ao restabelecimento da saúde do segurado constitui a própria essência do contrato de seguro saúde, qualquer atitude tomada pela operadora de plano de saúde que obstaculize a cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente, se mostra, a toda evidência, contrária à própria natureza do contrato, ameaçando seu objeto e o equilíbrio contratual, sendo, por isso, ilícita. 4. É obrigação da seguradora de saúde autorizar o serviço de saúde da maneira como requerido pelo

médico assistente, por ser ele detentor de capacidade técnica para justificar a sua indicação e responsável por ponderar se o tratamento é capaz de influir na cura da paciente, podendo apenas o plano de saúde eleger que doenças estarão ou não abrangidas pela sua cobertura. Precedentes. 5. A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no seu espírito. Casos de negativa de cobertura contratual por parte da operadora de saúde não pode ser visto como mero inadimplemento ou discussão contratual, caracterizando dano moral. Precedentes jurisprudenciais. 6. Constata-se que a parte ré, ora apelante, não trouxe informações capazes de rechaçar cabalmente as alegações do ator/apelado, não se desincumbindo de seu ônus probatório previsto pelo Art. 373, II, do CPC e sendo assim o reembolso integral das despesas contraídas pelo recorrido com o material cirúrgico deve ser deferido, tal como entendeu o juiz a quo não merecendo reparo sua decisão no tocante aos danos materiais sofridos.7. Em sessão, deliberando-se acerca do quantum indenizatório e tomando por base os pressupostos de razoabilidade e proporcionalidade que devem permear a fixação da indenização por danos morais, considerou o Colegiado como razoável a redução do valor arbitrado em sentença para R$ 7.000,00 (sete mil reais). 8. Recurso parcialmente provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE, Apelação Cível 0000092-19.2013.8.17.1280 (545551-4), Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior. Data do Julgamento: 05/02/2020).

PLANO DE SAÚDE – SEGURADO – CONTRATO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – DESCONSIDERAÇÃO – Os contratos celebrados para assistência à saúde, se identificam como de prestação de serviço e devem obediência às regras do Código de Defesa do Consumidor no que respeita às cláusulas ditas abusivas, como o são aquelas que colocam o usuário do serviço em desvantagem exagerada em relação àquele que os presta; a inadimplência de sessenta dias que autoriza a suspensão do contrato é aquela é a contínua e não a que soma pequenos dias de atrasos alternados ocorridos ao longo do pacto. **Constatado que o segurado estava com suas prestações atualizadas, a recusa em atendê-lo quando necessitou do serviço, é certa que lhe acarretou prejuízos de natureza moral e material, esta, quando ele teve que desembolsar recursos próprios para tratar-se de sua enfermidade**; o dano material é o que ficou, objetivamente, provado, enquanto que o dano moral, que tem natureza subjetiva, deve ser arbitrado, segundo as circunstâncias do caso, suas conseqüências, partes envolvidas, tendo sempre presente que a condenação, que reverterá em favor do ofendido, tem caráter educativo, e, por isso, há que ser arbitrada de modo a não se revelar insignificante, e, por outro lado, não deve ser tão elevada para não se converter em locupletamento (TJMA – AC 019119/2002 – (44.287/2003) – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Stélio Muniz – J. 24.04.2003). (Destaquei)

Na hipótese em exame, a condenação da ré a compensar os danos de ordem imaterial suportados pela demandante se impõe, a partir de uma estimação prudencial que leve em consideração o grau em que o prejuízo causado influiu no

seu ânimo e no seu sentimento:

A intensidade da culpa, a violência, as circunstâncias em que ocorreu o evento danoso poderão informar o critério a ser adotado em tal arbitramento, árduo e delicado, porque entranhado de subjetividade. (TJRJ - 8ª C. - Ap. - Rel. Silveira Neto - j. 29.10.92 - JTJ- LEX 142/104).

A vítima de lesão de direitos de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP - 7º Rel. Campos Mello j. 30.10.91 RJTJESP 137/187).

A reparação, nesse panorama, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aquilatados de acordo com as peculiaridades que envolvem o pleito (STJ - RESP 200500465226 - (736968) - RJ - 4ª T. - Rel. Min. Jorge Scartezzini - DJU 01.07.2005 - p. 00559).

Dito isto, em atenção aos critérios e princípios acima elencados e consideradas as peculiaridades do caso em comento, tenho que, diante das provas documentais constantes dos autos, houve perceptível inobservância da indispensável equidade da mesma no desenvolvimento do trato contratual avençado, propiciando plenas condições à respectiva ocorrência.

Concernente às repercussões do fato danoso, tenho-os como relevantes para abalar a personalidade da autora, principalmente por ocorrer no momento em que esta necessitava do devido respaldo econômico e de tranquilidade para se recuperar.

Destarte, consideradas as peculiaridades do caso em questão e tendo em vista os princípios de moderação e razoabilidade, entendo ser justo e necessário fixar o importe compensatório pertinente em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo tal imposição plenamente justificável para que de um lado se tenha a devida compensação pelos transtornos passados pela autora e, de outro, medida verdadeiramente pedagógica, pois destinada a de tentar evitar a reiteração da conduta perpetrada pela demandada, explicitamente prejudicial aos seus contratantes, consumidores.

4. Dispositivo.

Ante o exposto, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e JULGO PROCEDENTE, em parte a pretensão autoral o pedido para condenar a **FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA,** a custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da demandada – idosa, acometida de várias doença, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado – na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, reincluindo a mesma no PROGRAMA PAIC/ ZELAR ATENDIMENTO DOMICILIAR, consoante prescrição médica, por período suficiente para cobrir o tratamento, sem prejuízo de outros tratamentos prescritos,

limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. Condeno, ainda, a ré a pagar indenização por danos morais a autora no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizada monetariamente pela tabela do ENCOJE, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, tudo contado da data desta sentença.

Condeno a demandada a pagar custas e honorários advocatícios que ora fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

No caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios (inclusive voltados à mera rediscussão do julgado), aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3º do mesmo artigo.

Interposta a apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC, que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos definitivamente.

VIA ELETRONICAMENTE ASSINADA SERVIRÁ COMO EXPEDIENTE DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL.

RECIFE, 22 de março de 2023

JJ Florentino dos Santos Mendonça

Juiz de Direito